

1501486-48.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... na residência. Já foi processado por tráfico e, na infância, foi processado duas vezes também por tráfico. Por fim, disse que possui dezenove anos e não conhecia os policiais que o abordaram.

Ocorre que versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga seria para seu consumo, não convence, vez que restou isolada no contexto probatório, que o compromete.

De fato, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba - SP - cep 16015-600

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501486-48.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501486-48.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS REIS CARVALHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcel Peres Rodrigues

V I S T O S.

WESLEY DOS REIS CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de outubro de 2021, por volta das 21:45 horas, na Rua Fundador Paulino Gatto, nº 1.124, no Bairro São José, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, duas porções de maconha com peso total de 501,75 gramas, substância esta capaz de causar dependências psíquica.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar a fls. 105/106. A denúncia foi

recebida a fls. 111/113. No decorrer da instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, interrogado o acusado (fls. 138/139).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia (oralmente, conforme fls. 135, e aditamento de fls. 153/156), ao passo que a Defesa requereu a desclassificação da conduta imputada na inicial para o crime previsto no artigo 28 da lei de Drogas. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo e da atenuante de menoridade relativa, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (oralmente, conforme fls. 135, e aditamento de fls. 159/163).

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 24, laudo de constatação provisória de fls. 26 e exame químico de entorpecentes encartado a fls. 55/57, que resultaram positivos para maconha.

E a responsabilidade criminal do acusado é indubitosa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime de tráfico. Disse que é usuário de drogas e consome aproximadamente 25 gramas de maconha por dia. Confirmou que a droga apreendida lhe pertence, tendo pago o valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por ela, que seria destinada ao seu consumo. Trabalhava na “brinquelândia” como monitor, mas foi afastado em razão da pandemia, sendo que recebia de R\$ 50,00 a R\$ 100,00 por festa. No dia dos fatos estava na rua e, ao avistar a viatura, entrou em sua casa. Estava carregando a porção de maconha que foi posteriormente apreendida pelos policiais. Havia acabado de comprar a droga. Sua irmã estava em casa no dia e autorizou a entrada dos policiais na residência. Já foi processado por tráfico e, na infância, foi processado duas vezes também por tráfico. Por fim, disse que possui dezenove anos e não conhecia os policiais que o abordaram.

Ocorre que versão apresentada pelo réu, no sentido de que a droga seria para seu consumo, não convence, vez que restou isolada no contexto probatório, que o compromete.

De fato, ouvidos em Juízo, os policiais Gleyson Donizete Alves e Ciro Cesar Ravanhani de Lima afirmaram que na noite dos fatos estavam em patrulhamento pela Rua Fundador Paulino Gatto, local conhecido como ponto de venda de drogas, e perceberam que um indivíduo, ao avistar a viatura, saiu correndo e ingressou em uma casa de esquina. Perceberam, ainda, que o indivíduo estava segurando algo que trazia consigo na cintura, sob a roupa. Deram a volta com a viatura e esperaram que o indivíduo pulasse o muro dos fundos da casa para se evadir, o que não aconteceu. Diante disso, chamaram pelos moradores da casa e foram atendidos por uma mulher, que se identificou como Thais, moradora da residência. Indagada se havia percebido alguém ingressando na casa, ela disse que não e autorizou os policiais a ingressarem no quintal à procura da pessoa que avistaram. Estavam entrando na casa quando o réu, que reconheceram como sendo a pessoa que havia se evadido e entrado na casa, se aproximou e se apresentou como morador. Ele foi revistado e nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Indagado sobre o motivo de ter se evadido, o réu disse que tinha droga em seu quarto para seu consumo. Localizaram um tijolo de maconha e um pedaço menor da mesma droga no quarto do réu. Ele disse que havia comprado o entorpecente de uma pessoa desconhecida pelo valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Informaram que nunca haviam abordado o acusado e que não havia

denúncias de tráfico por parte dele no dia fatos.

E o destino do entorpecente apreendido em poder do réu é manifesto, vez que trazia consigo e tinha em depósito uma expressiva quantidade de entorpecente (501,75 gramas de maconha), na forma de tijolo, o que indica que o destino não seria o consumo. Mas não é só. O réu não possuía emprego lícito comprovado nos autos (disse em Juízo que estava afastado de seu trabalho em razão da pandemia), de forma que, evidentemente, não teria condições econômicas de adquirir tamanha quantidade de droga de uma só vez e sustentar seu alegado vício se não fosse o suporte financeiro advindo do tráfico de entorpecentes.

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a finalidade de tráfico de entorpecentes é evidente, ficando afastada a tese defensiva de desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Neste sentido:

“Levando-se em conta a grande quantidade de entorpecente encontrada, o valor e o escasso poder de compra do acusado, aliando-se ao fato de que levava ao local de serviço, tem-se que está correta a classificação do delito no art. 12 da Lei 6368/76” (TJ-SP - AC 161.748-3-0 - Rel. Gentil Leite - RT 710/279).

“Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente, confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no artigo 12 da Lei 6368/76” (TJRS - AC - Rel. Oswaldo Proença - RJTJRS 145/115).

Consigno, ainda, que a condição de usuário ou de dependente não exclui a de traficante, muito pelo contrário, pois infelizmente a prática ensina que muitos usuários passam a comercializar drogas para conseguir sustentar o vício.

Nesse sentido “Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (TJSP - AC 9.751-3 - Rel. Gonçalves Sobrinho - RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente - Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível - Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

Verifica-se, portanto, que a prova acusatória forma um todo coeso e concorde, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, afastando-se toda e qualquer tese absolutória.

Assim, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, em face da sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

O réu não ostenta antecedentes criminais. Analisando, ainda, as demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria penal, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade relativa porque a pena base já foi fixada em seu patamar mínimo legal e no direito

brasileiro "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula nº 231 do STJ).

Na terceira fase de dosimetria penal, o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Isso porque, embora primário, o acusado, enquanto adolescente, cumpriu medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de entorpecentes (fls. 140/142). Não bastasse, o réu, que possuía apenas 18 anos de idade na época dos fatos, praticou o crime objeto destes autos enquanto se encontrava em gozo de liberdade provisória, concedida no processo nº 1500639-46.2021.8.26.0603, pelo qual também responde pela prática de crime de tráfico de drogas (fls. 77). Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o acusado não possui emprego lícito comprovado nos autos, permitem concluir que ele não se trata de mero traficante ocasional, mas sim que, desde a adolescência, se dedica às atividades criminosas, fazendo do tráfico seu meio de vida e fonte de renda. Assim, o réu não preenche os requisitos necessários à concessão do benefício ---"desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa---. Neste sentido: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. SITUAÇÃO IDÔNEA A SER VALORADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE DROGA. USO NA PRIMEIRA FASE E NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Quanto ao pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, frise-se que, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III - In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack. IV - De mais a mais, o Tribunal de origem afirmou que o paciente "assume funções de chefia e direção em organização criminosa. Acrescente-se que, conforme documento de fl. 52, o réu apresenta inúmeras passagens pela Vara da Infância, fazendo do crime o seu meio de vida desde a adolescência". Com efeito, "a Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (AgRg no HC n. 588.716/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/08/2020). V - Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017. VI - Ainda, insta consignar que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base, e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.255.180/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 15/02/2013; HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; HC n.

379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017; AgRg no REsp n. 1.779.825/RO, Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/05/2019. VII - Regime inicial. A quantidade e a natureza do entorpecente - 1.364,77 g de cocaína; e 489,51 g de crack - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: HC n. 488.679/SP, Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019; e AgRg no HC n. 380.021/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 22/3/2017. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 641.285/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021). "TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos dos guardas civis municipais em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada - Apreensão de razoável quantidade de entorpecente (16 porções de 'maconha', com peso líquido de 18,11 gramas), além de dinheiro e celular - Crime cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvendo adolescentes - Condenação eskorreita. PENAS E REGIMES PRISIONAIS - Bases nos mínimos. Natureza e quantidade de droga que, embora relevante, não justificam a exasperação - Menoridade relativa e agravante do artigo 61, II, "j", do CP (crime praticado durante estado de calamidade pública). Compensação - Exclusão do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Réu que ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, três delas por ato infracional equiparado ao tráfico. Causas de aumento do artigo 40, III e VI, da Lei de Drogas. Acréscimo de 1/5 - Regime inicial fechado - Apelo ministerial provido para afastar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, majorar as penas e fixar o regime inicial fechado. (TJSP; Apelação Criminal nº 1501321-34.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Des. Relator: Gilberto Ferreira da Cruz; Data de Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEFESA PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA QUE SEJA ELEVADA A PENA-BASE, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXADO O REGIME FECHADO E CASSADA A SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS - COM INTEIRA RAZÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO - PENAS ALTERADAS - RÉU PRIMÁRIO, MAS COM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEDICAÇÃO AO NEFASTO COMÉRCIO DEMONSTRADA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA - IMPOSSIBILIDADE DE PERMUTA E DE RIGOR O REGIME FECHADO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DE EMPREITADA CRIMINOSA - A MULTA NÃO PODE SER REDUZIDA, POIS JÁ SE ENCONTRA NO MÍNIMO LEGAL - EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO -RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal nº 1500927-84.2019.8.26.0628; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Des. Relator: Euvaldo Chaib; Data de Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020).

Portanto, ante a ausência de circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena aplicada.

O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WESLEY DOS REIS CARVALHO, qualificado nos autos, e o condeno ao cumprimento de cinco anos de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O regime para o cumprimento de pena é o inicial fechado, único recomendável diante da latente e concreta gravidade do crime (o réu se dedica ao tráfico de drogas, não se enquadrando o delito em questão na figura do chamado "tráfico privilegiado", como já visto), fomentador de tantas outras práticas ilícitas, restando evidentemente prejudicada a aplicação da Lei nº 9.714/98, mesmo porque os objetivos

do legislador com a promulgação desta Lei demonstram que ela afeta apenas aos crimes menos graves, distanciam-se em muito da hedionda mercancia.

Demais disso, ainda que alguns requisitos do artigo 44, do Código Penal fossem favoráveis ao réu (o que não é o caso, vez que a pena aplicada é superior a quatro anos de reclusão), não estaria configurado o previsto pelo inciso III, in fine, do mencionado dispositivo legal, ou seja, "os motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente". O traficante é um grande responsável direto pela onda de violência que avassala o país. A insuficiência da substituição em tela para a repressão e prevenção do tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto é patente, por conseguinte.

Considerando-se a gravidade do delito cometido pelo réu, o regime de pena imposto, e mormente o fato de ter sido preso em flagrante delito e encontrando-se detido até hoje, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu, apesar de primário e de bons antecedentes, respondeu a ação penal, quando havia apenas o "fumus boni iuris", preso, após a prolação de sentença, surge a certeza que exclui a possibilidade do recurso em liberdade" (RJDTACRIM 13/181). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Logo, o réu não poderá recorrer em liberdade, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra, mesmo porque continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, como já exposto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e na que a manteve.

Ressalto que eventual detração penal (art. 387, § 2º do CPP) deve ser postulada, oportunamente, ao juízo das execuções criminais competente, o qual possui condições de aferir a presença dos requisitos legais, especialmente os de natureza subjetiva.

Neste sentido: "Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar. Nulidade das provas obtidas mediante atuação da guarda municipal. Prisão em flagrante. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Preliminar afastada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas escorreitas. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade, nocividade e diversidade de droga apreendida. Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2º, CPP). Competência do juízo das execuções penais. Recurso não provido" (TJSP; ApelaçãoCriminal1500272-11.2021.8.26.0542; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador:8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/01/2022; Data de Registro: 17/01/2022).

Após o trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral.

Custas na forma da Lei.

P. I.C.

Araçatuba, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA